

1500701-06.2020.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas anteriormente cometidos pelo agente sejam aptos a caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado (HC n. 199.060/SP, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/3/2021). 4.

Incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500701-06.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500701-06.2020.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO VITOR MOREIRA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

PAULO VITOR MOREIRA PEREIRA foi processado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 30/3/2020, por volta das 16h20, na Rua Alvorada, n. 100, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, 40 (quarenta) porções de cocaína (massa bruta de 69,92 gramas e líquida de 29,28 gramas), 32 (trinta e duas) porções de cocaína petrificada (massa bruta de 28,76 gramas e líquida de 4,84 gramas) e 10 (dez) porções de maconha (massa bruta de 15,72 gramas e líquida de 15,02 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, apresentou resposta às fls. 203/205, esclarecendo que foi perseguido e abordado, sem flagrante de venda de drogas.

A denúncia foi recebida por decisão proferida às fls. 209/210, em 17/12/2021.

Realizadas audiências de instrução (fls. 247/249 e 257/258), foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório. Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da peça acusatória, com fixação de regime inicial fechado e afastamento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 261/274). A defesa afirmou que o acusado foi ao local apenas para comprar maconha, sem provas de traficância, impondo-se a absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Max Ferreira, guarda municipal, disse que local dos fatos é conhecido ponto de tráfico; não se recorda de muita coisa; estavam na viatura, quando acusado viu a guarnição empreendeu fuga; correu atrás pelas casas (escadão); "a gente acabou encurralando ele"; parceiro fechou em saída de uma casa; em revisto pessoal encontraram drogas e dinheiro, mas não se recorda quanto; sobre tipos de drogas: tinha todas - maconha, crack e cocaína (não sabe com certeza, mas que havia grande variedade); não se lembra de forma de acondicionamento; conduziram para a delegacia; lembra que usava uma pochete; estava parado no escadão e tinha mais alguém lá, mas não sabe se estava vendendo; não tem como afirmar se acusado estava vendendo.

Maikon Leno Ribeiro dos Santos, guarda municipal, expôs que estava com parceiro Max na viatura; local conhecido como ponto de venda/uso; quando avistou viatura, acusado tentou evadir; parceiro desembarcou e correu para um lado; depoente correu para outro; conseguiram abordá-lo; tinha droga, dinheiro e celular; droga em uma pochete, em posse de Paulo Vitor (no corpo); foi abordado pelo depoente; três tipos de droga [maconha, cocaína e crack]; no primeiro momento disse que estava vendendo; na delegacia negou; estavam em viatura caracterizada; acusado não é conhecido dos meios policiais; não presenciou vendendo, mas afirmou que vendia quando abordado. Com efeito, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2); boletim de ocorrência n. 1151/2020 (fls. 6/8); auto de exibição e apreensão (fls. 9/12); laudo de constatação preliminar (fls. 14/16); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 97/99), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, boletim de ocorrência do dia dos fatos (fls. 253/254), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em Juízo.

A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado.

Em seu interrogatório relatou que não "trabalhava" mais na biqueira; tinha parado; estava no escadão; foi comprar maconha; do nada apareceu carro preto com vários policiais fardados; estava sentado com 4 (quatro) amigos; quando viu carro saiu correndo; não eram suas as porções apreendidas; droga estava dentro do carro; policiais falaram que era do depoente; nunca teve problema com os GCMS; já vistos fazendo ronda; tinha apenas R\$ 5,00 para comprar maconha.

Apesar de ter alegado que as drogas não lhe pertenciam e que pretendia comprar uma porção de maconha, de se consignar que ambas as testemunhas relataram que estava com uma pochete, dentro da qual, segundo o relato de Maikon, estavam as drogas, em quantidade e variedade incompatível com a finalidade alegada.

Não se ignora a existência de precedentes do TJ/SP determinando a desclassificação da conduta quando da fragibilidade da prova acusatória: "TRÁFICO DE DROGAS.

Necessária a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de maconha apreendidas. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-10.2020.8.26.0165; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021)" - grifou-se.

Todavia, além de preso em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer indício que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais, reitera-se, são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia. Em reforço, o STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos

entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE 28/6/2021)" – grifou-se.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fls. 9/12); laudo de constatação preliminar (fls. 14/16); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 97/99), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse do acusado, aliados às ponderações acima, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, o acusado foi preso com 29,28 gramas de cocaína em pó, 4,84 gramas de cocaína em pedra, e 15,02 gramas de maconha, quantidade módica e incompatível com o acréscimo da reprimenda. Em reforço: "Consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Embora a nocividade da droga seja critério idôneo para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal, o caso envolveu a apreensão de pequena quantidade de entorpecente, o que, por questão de proporcionalidade, enseja a redução da pena-base para o piso legal" (STJ, HC n. 398.722/SC) – grifou-se.

As demais circunstâncias não excedem a gravidade inerente a o tipo, fixando-se a reprimenda no mínimo legal.

Na segunda fase, apesar de menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ), mantida no piso legal.

Na terceira fase, verifica-se que o acusado foi condenado pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (processo n. 0002382-90.2017.8.26.0544 – fl. 256).

Com efeito, no EREsp n. 1.916.596, o STJ assentou que "apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescendo a execução penal [...]. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena [...]. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" – grifou-se.

Por sua vez, o STF, em ambas as turmas, tem entendimento que os atos infracionais pretéritos não constituem fundamento idôneo para afastar a benesse do art. 33, § 4º: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA

DE DIMINUIÇÃO DA PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A NEGAR O REDUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA PARA SE REFAZER A DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A prática anterior de atos infracionais pelo paciente não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 4. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente elididos. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido" (HC 191992 Agr) – grifou-se.

Ainda: "EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício. Precedente. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de registro pretérito de atos infracionais não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, a quantidade de drogas não expressiva, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços), inexistente, ainda, circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de fração menor. 4. Agravo regimental conhecido e não provido" (HC 214089 Agr).

No caso, entre a prática do ato infracional (4/11/2017 - autos n. 0002382-90.2017.8.26.0544) e o crime em análise (30/3/2020), passaram pouco mais de 2 (dois) anos. Em caso semelhante, o STJ entendeu pela aplicação da benesse: "Trata-se do tráfico de apenas 31,2 g de crack, praticado 2 anos e 6 meses após o cumprimento de medida socioeducativa por ato infracional análogo, não havendo falar em razoável proximidade temporal entre as condutas. [...] Na hipótese, contudo, foram apreendidos 17,42 gramas de maconha e 4,45 gramas de cocaína em 24/12/2019, quantidade considerada não relevante por esta Corte, que, dada a ausência de circunstâncias adicionais, indica a adequação da minorante do tráfico privilegiado, não obstante a existência de atos infracionais anteriores ocorridos em 2015, 2016 e 2017. 4. A infração em causa é de 22/7/2019, mais de dois anos depois do último ato infracional, não havendo a razoável proximidade temporal referida no citado EREsp n. 1.916.596/SP (AgRg no AREsp n. 1.909.287/SP, Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022). 3. Do Supremo Tribunal Federal, colhe-se que a jurisprudência [...] vem se encaminhando no sentido de não admitir que atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas anteriormente cometidos pelo agente sejam aptos a caracterizar Maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado (HC n. 199.060/SP, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/3/2021). 4. Incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 que se impõe. 5. Agravo regimental improvido" (AgRg no HC 724495/SP).

Feitas tais ponderações, é caso de deferir ao acusado os benefícios do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Logo, de rigor a redução da pena em 2/3, resultando pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no

regime inicial aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP), além de 166 dias-multa; o valor da multa vai fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana, por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; consigna-se que foi condenado a pena inferior a quatro anos, não é reincidente nem possui antecedentes criminais, de modo que a substituição, mais que suficiente ao caso, constitui direito subjetivo do acusado (art. 44 e § 2º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar PAULO VITOR MOREIRA PEREIRA pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito meses) de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; além de 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Diante da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento com a prisão preventiva, descabida sua decretação (art. 387, § 1º, do CPP).

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Decreta-se o perdimento do valor e bens apreendidos (fls. 9/12) (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§ 1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado nos termos dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

PIC.

Campo Limpo Paulista, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA